

<제5장 취소소송의 심리.제2절 위법성 판단의 기준시>

I. 의의

- 위법성 판단의 기준시 문제는 취소소송에서 심리의 핵심 쟁점 중 하나이다. 행정처분 이후 법원의 판결까지 기간 동안 처분의 근거가 되는 법령이 변경되거나 처분의 기초가 되는 사실 상태에 변동이 발생하는 경우가 있다. 이러한 경우 법원이 처분의 위법 여부를 판단할 때 언제를 기준 시점으로 삼아야 하는지에 대한 견해 대립이 발생한다. 이는 법적 안정성의 요청과 구체적 타당성 및 국민의 실질적 권리 구제 요청이 충돌하는 지점이며, 특히 행정청의 재량 행위 심사 범위와도 밀접하게 관련된다. 이하에서는 취소소송과 거부처분취소소송에서의 위법성 판단 기준시를 검토한다.

II. 취소소송에서의 위법성 판단의 기준시

1. 학설

(1) 처분시설

- 처분시설은 행정처분의 위법성 판단은 처분 당시의 법령과 사실 상태를 기준으로 해야 한다는 견해이다. 취소소송은 행정청이 이미 행한 처분의 적법 여부를 사후적으로 심사하는 소송이므로, 처분 당시를 기준으로 판단해야 법적 안정성이 확보되고 행정청의 적법한 권한 행사가 존중될 수 있다고 본다. 이 견해에 따르면 처분 후 사정 변경은 위법성 판단에 영향을 미치지 않는다.

(2) 판결시설

- 판결시설은 행정처분의 위법성 판단은 법원의 판결 당시의 법령과 사실 상태를 기준으로 해야 한다는 견해이다. 행정소송의 목적이 위법한 상태의 제거 및 국민의 현실적인 권리 구제에 있으므로, 현재 시점의 법질서에 비추어 처분의 위법 여부를 판단하는 것이 타당하다는 입장이다. 이 견해는 구체적 타당성 확보에 유리하지만, 행정청의 처분 시 판단 권한이 과도하게 침해될 수 있다는 문제점이 있다.

(3) 절충설

- 절충설은 사실 인정의 기준시는 처분시로 하되 법률 적용의 기준시는 판결시로 해야 한다는 등의 다양한 입장을 취하며, 처분시설과 판결시설의 장점을 절충하려는 시도이다. 그러나 사실 인정과 법률 적용을 엄격하게 분리하기 어렵다는 점에서 실질적인 적용이 용이하지 않다.

2. 판례

- 판례는 일반적인 취소소송에서 위법성 판단의 기준시를 처분시설로 일관되게 보고 있다. 행정처분의 위법 여부는 행정처분이 있을 당시의 법령과 사실 상태를 기준으로 판단해야 하며, 처분 후 법령이 개정되거나 사실 상태가 변동되었다고 하더라도 이를 고려하여 위법 여부를 다시 판단할 수는 없다는 것이다. 이는 취소소송이 처분의 적법성을 심사하는 소극적인 기능에 충실하고자 하는 태도이다. 다만, 처분 후 사정 변화가 있는 경우 그것이 현저히 공공복리에 적합하지 않다고 인정되면 위법성을 인정하면서도 사정판결을 내릴 수 있다는 예외 규정이 존재한다.

3. 검토

- 취소소송의 위법성 판단 기준시로서는 처분시설이 타당하다. 취소소송은 행정청이 권한을 행사한 시점의 판단이 정당했는지 여부를 심사하는 것이 본질이기 때문이다. 행정청은 처분 당시 존재하는 법규와 사실에 기초하여 처분할 의무가 있으며, 그 당시의 법규 상태를 벗어나 처분의 적법 여부를 논할 수는 없다. 처분 후 발생한 법령 변화 등을 이유로 처분을 취소하게 되면 행정청의 처분 시 판단이 정당했음에도 불구하고 사후적으로 위법하게 취급되는 불합리가 발생한다. 구체적 타당성 문제는 사정판결 제도 등을 통하여 보완할 수 있다.

III. 거부처분취소소송에서의 위법성 판단의 기준시

1. 학설

(1) 처분시설

- 거부처분 역시 일반 행정처분과 마찬가지로 처분시설이 적용되어야 한다고 보는 견해이다. 거부처분도 하나의 행정처분이므로 법적 안정성 확보 및 행정청의 권한 존중이라는 일반 취소소송의 논리가 그대로 적용되어야 한다는 입장이다. 따라서 거부 당시의 법령 및 사실 상태를 기준으로 위법 여부를 판단해야 한다.

(2) 판결시설

- 거부처분취소소송의 궁극적인 목적은 신청에 따른 인용 처분을 받아내는 데 있으므로, 가장 최근의 사실심 변론종결시 즉, 판결시를 기준으로 행정청이 처분을 해줄 의무가 현재 존재하는지 여부를 판단해야 한다는 견해이다. 이는 거부처분 취소판결의 실효성 확보 및 국민의 실질적인 권리 구제 측면에서 유리하다는 논거를 든다.

(3) 절충설

- 거부처분 자체의 위법성 판단은 처분시를 기준으로 하되, 취소판결에 따른 행정청의 재처분 의무 이행 시 판단의 기준시는 판결시를 기준으로 해야 한다는 견해이다. 이는 법원의 심사 범위와 행정청의 재처분 범위를 구별하는 입장이다.

2. 판례

- 판례는 거부처분취소소송에서도 원칙적으로 일반 취소소송과 마찬가지로 처분시설을 채택하고 있다. 즉, 거부처분의 위법 여부는 그 거부처분 당시의 법령 및 사실 상태를 기준으로 판단해야 한다는 것이다. 따라서 거부처분 후 관계 법령이 개정되어 신청인에게 유리하게 되었다 하더라도, 이는 재처분 시 행정청이 고려할 사정일 뿐, 기존 거부처분의 위법성 판단에는 영향을 미치지 않는다. 다만, 거부처분이 취소되어 행정청이 재처분을 할 때에는 판결의 기속력에 따라 처분시를 기준으로 할 수 없고 재처분 당시의 법령과 사실 상태를 기준으로 하여 다시 처분해야 한다는 입장이다.

3. 검토

- 거부처분취소소송에서는 거부처분 자체의 위법성 판단 기준시는 처분시설이 타당하다. 이는 취소소송의 본질이 기존 행위의 적법성 심사에 있기 때문이다. 그러나 거부처분 취소판결의 실효성을 확보하기 위해서는 판결의 기속력을 통해 행정청이 재처분을 할 때 판결시 또는 재처분시의 법률 및 사실 상태를 반영하도록 해야 한다. 판례는 이러한 두 가지 측면을 고려하여 위법성 판단 자체는 처분시설에 따르되, 재처분 의무에는 당시의 사정을 반영하도록 하는 절충적 태도를 취하고 있다고 볼 수 있다.

IV. 결론

- 취소소송에서 위법성 판단의 기준시는 원칙적으로 법적 안정성을 위해 처분시설을 취하는 것이 타당하며, 판례 역시 이러한 입장이다. 거부처분취소소송에서도 거부 행위 자체의 위법성 판단은 처분시설에 의하는 것이 원칙이지만, 취소판결 후 행정청의 재처분 의무 이행 시에는 판결의 기속력에 따라 재처분 당시의 법률 및 사실 상태를 기준으로 처분해야 한다. 이는 위법한 행정행위의 제거라는 취소소송의 본질과 국민의 실질적인 권리 구제라는 목표를 동시에 달성하기 위한 접근이다.